

(18)

FATIN SYAZANA BINTI HARUN

lwn

AHMAD ZAKI BIN SAMID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 22 April 2022 bersamaan 20 Ramadan 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0002-2022

[Permohonan Semakan Perintah Interim Hadhanah Inter-Parte di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan kes interim hadanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam kes permohonan mal no. 10100-038-0253-2021 pada 09/12/2021.

[2] Melalui Notis Permohonan dan Afidavit yang diikrarkan pada 15/9/2021 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut –

- i. Mahkamah Yang Mulia ini menyemak keseluruhan Perintah bertarikh 09/12/2021 di dalam kes Permohonan No: 10100-038-0253-2021;
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini mengenepikan atau membatalkan Perintah bertarikh 09/12/2021;
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini mengekalkan Perintah Interim *ex-parte* bertarikh 07/05/2021 sehingga kes hadanah diputuskan;
- iv. Lain-lain relif yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Pada 06/05/2021 Pemohon telah memfailkan Permohonan Interim Hadanah secara *ex-parte* melalui kes permohonan no: 10100-038-0253-2021 tanpa diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie.

[4] Pada 07/05/2021 permohonan tersebut telah didengar dan telah diluluskan oleh Yang Arif Hakim Bicara. Perintah tersebut kemudiannya telah diserahkan kepada pihak Responden. Terma-terma perintah adalah sebagaimana berikut :

4.1 *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

- 4.2 Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara bagi dua anak bernama :
- i. Aimey Hadejah binti Ahmad Zaki (No Mykid : 081021-04-0202)
 - ii. Emir Ali bin Ahmad Zaki (No Mykid : 140404-16-0145)
- (selepas ini disebut anak-anak tersebut) diserahkan kepada Pemohon (ibu).
- 4.3 Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada waktu-waktu yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan kepada Pemohon terlebih dahulu.
- 4.4 Mahkamah memerintahkan Responden atau ahli keluarga Responden atau mana-mana individu yang dipercayai bahawa anak tersebut dibawah jagaan mereka diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon sebaik sahaja Perintah Interim ex-parte ini disampaikan.
- 4.5 Perintah Interim ex-parte ini hendaklah diserahkan kepada Responden dalam tempoh 7 hari dari perintah ini dikeluarkan.
- 4.6 Responden diberi hak untuk mengenyahkan Perintah Interim ex-parte ini dalam tempoh 14 hari dari penerimaan perintah ini.
- 4.7 Perintah Interim ex-parte ini hanya berkuatkuasa selama 30 hari dari tarikh perintah ini dikeluarkan.
- 4.8 Pihak Polis Di Raja Malaysia dan lain-lain pihak berkuasa agama hendaklah memberikan kerjasama kepada Pemohon didalam melaksanakan Perintah Interim ex-parte ini.
- 4.9 Kes ditangguhkan pada 03/06/2021 jam 9.00 pagi untuk sebutan.

[5] Seterusnya pada 10/11/2021 kes telah disebut untuk kali pertama dengan kehadiran Responden. Responden telah menyatakan hasratnya untuk mengenyah dan

membatalkan perintah *ex-parte* tersebut. Oleh yang demikian Yang Arif Hakim Bicara telah mengarahkan Responden supaya memfailkan Affidavit Jawapan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tersebut. Kes kemudiannya ditetapkan untuk disebut semula pada 09/12/2021. Namun begitu Pemohon mendakwa tidak menerima sebarang Affidavit Jawapan sehingga semakan ini difailkan.

[6] Pada 06/11/2021 Pemohon telah memaklumkan kepada Pembantu Hakim bahawa Pemohon telah diarahkan supaya menjalani kuarantin kerana menjadi kontak rapat pesakit Covid 19. Oleh yang demikian Pemohon tidak dapat menghadiri prosiding yang telah ditetapkan pada 09/12/2021. Berhubung dengan perkara tersebut, Pemohon juga telah diminta oleh Pembantu Hakim untuk memaklumkan secara bertulis ketidakhadiran melalui emel dan telah berbuat demikian pada 08/12/2021.

[7] Pada 01/01/2022 Pemohon telah menerima salinan Perintah bertarikh 09/12/2021 daripada Responden melalui aplikasi *whats app* dan telah diminta supaya menyerahkan anak pertama kepadanya berdasarkan perintah tersebut. Terma-terma perintah adalah sebagaimana berikut :

7.1 *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara yang bernama Aimey Hadejah binti Ahmad Zaki (No Mykid : 081021-04-0202) dan Emir Ali bin Ahmad Zaki (No Mykid : 140404-16-0145)(Selepas ini disebut anak-anak tersebut) diberikan kepada Pemohon (Ibu).*

7.2 *Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Responden (Bapa) pada minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu Kedua dan Keempat anak-anak tersebut bersama*

dengan Pemohon (Ibu). Cuti sekolah dibahagi dua, bahagian pertama bersama Responden dan bahagian kedua bersama Pemohon.

7.3 *Mahkamah memerintahkan bahawa Hari Raya Aidilfitri tahun ini, raya pertama bersama dengan Responden. Hari raya Aidilfitri kedua petang Responden hendaklah memulangkan anak-anak tersebut kepada Pemohon dan bergilir untuk tahun-tahun seterusnya.*

7.4 *Mahkamah memerintahkan bahawa Hari Raya Aidiladha tahun ini, raya pertama bersama dengan Pemohon dan raya kedua bersama dengan Responden dan begilir untuk tahun-tahun seterusnya.*

7.5 *Mahkamah memerintahkan hari-hari biasa Responden boleh melihat anak-anak tersebut.*

7.6 *Mahkamah memerintahkan Perintah Sementara ini berkuatkuasa mulai hari ini sehingga ada perintah lain yang membatalkannya atau kes induk diputuskan.*

[8] Tidak berpuas hati dengan keputusan dan perjalanan prosiding kes tersebut yang diputuskan tanpa kehadirannya maka semakan ini difailkan.

Alasan Semakan

[7] Bagi menyokong permohonan semakan ini, Pemohon telah mengemukakan empat (4) alasan sebagaimana yang terkandung dalam afidavit bertarikh 06/01/2022. Disini kami perturunkan satu persatu alasan yang dimaksudkan seperti berikut –

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan kes permohonan no : 10100-038-0253-2021 tanpa melalui prosedur perbicaraan;

- ii. Yang Arif Hakim telah memutuskan kes permohonan no : 10100-038-0253-2021 tanpa kehadiran Pemohon yang telah dimaklumkan kepada pihak mahkamah dua hari sebelum tarikh sebutan disebabkan Pemohon diarahkan kuarantin;
- iii. Yang Arif Hakim terkhilaf apabila memutuskan kes dengan hanya berdasarkan keterangan Responden semata;
- iv. Yang Arif Hakim terkhilaf apabila memutuskan kes dengan mengambil keterangan Responden sahaja walhal Responden telah gagal memfailkan bantahan dan/atau Afidavit Jawapan terhadap Perintah Interim (*ex-parte*) bertarikh 07/05/2021 dalam tempoh 14 hari dari tarikh yang diarahkan oleh Yang Arif Hakim.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Sukacita untuk kami tegaskan bahawa sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar diambil mudah tanpa alasan yang kukuh menurut undang-undang. Hal ini kerana proses semakan adalah bertujuan menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

[9] Ini bermakna apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan kriteria-kriteria bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Peraturan-peraturan yang relevan dalam kes semakan ini adalah peraturan 5 dan 7 yang kami perturunkan sebagaimana berikut :

Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

Perenggan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

[11] Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2), Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2), Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan

No. 10000-003-0009-2011 dan Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[13] Bagi melaksanakan proses semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan N o.10100-038-0253-2021. Penelitian terhadap fail atau rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti apakah wujud sebarang kecacatan sepanjang perbicaraan atau terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[14] Berdasarkan alasan-alasan semakan yang dinyatakan, kami menyimpulkan isu yang dibangkitkan adalah berkenaan kekhilafan Yang Arif Hakim Bicara yang memutuskan kes tanpa kehadiran Pemohon dan hanya berdasarkan keterangan Responden sahaja. Oleh itu persoalan yang berbangkit di hadapan kami adalah sama ada ianya merupakan suatu kecacatan dari sudut tatacara dan bercanggah dengan hukum Syarak atau sebaliknya.

[15] Bagi memutuskan isu ini kami telah merujuk kepada Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi sebagaimana yang terdapat di dalam Arahan Amalan No.5 Tahun 2016. Dalam konteks semakan ini, peraturan 11 garis panduan tersebut menyatakan :

11. Prosiding Inter Parte

- (1) Responden selepas menerima notis permohonan ex parte, affidavit permohonan ex parte dan perintah ex parte, boleh memfailkan affidavit jawapan bagi tujuan mengenepikan/membatalkan/mengubahsuai perintah ex parte tersebut dalam tempoh 14 hari dari penerimaanya.*
- (2) Tiada affidavit balasan boleh difailkan oleh Pemohon, melainkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada mahkamah.*
- (3) Pada masa yang ditetapkan bagi pendengaran inter-parte, mahkamah boleh, setelah meneliti semua affidavit dan hujah kedua-dua belah pihak sama ada mengenepi atau meminda atau mengekalkan perintah ex-parte berkenaan sebagai perintah interim.*

Prosiding inter parte tersebut hendaklah diselesaikan sebelum tamat tempoh kuatkuasa perintah ex parte.

- (4) Sekiranya pemohon tidak hadir semasa pendengaran inter-parte, Mahkamah boleh mengenepikan/membatalkan/mengubahsuai perintah ex-parte tersebut dan jika responden tidak hadir pada tarikh pendengaran, mahkamah boleh menjadikan perintah ex-parte tersebut sebagai perintah interim.*

[16] Berdasarkan peraturan 11(4) di atas, adalah jelas menunjukkan bahawa sungguhpun tanpa kehadiran Pemohon, Mahkamah masih boleh meneruskan prosiding dan membuat keputusan sama ada untuk mengenyah, membatalkan atau mengubahsuai apa-apa terma dalam perintah *ex-parte* yang telah diputuskan. Pada hemat kami juga kegagalan Responden untuk memfailkan Affidavit Jawapan tidaklah menghalang Yang Arif Hakim Bicara untuk mengambil apa-apa keterangan secara lisan. Dalam kes ini Yang Arif Hakim Bicara telah berbuat demikian semasa prosiding *inter parte* bertarikh 09/12/2021.

[17] Merujuk kepada rekod perbicaraan juga menunjukkan bahawa Mahkamah Bicara telah mengambil maklum ketidakhadiran Pemohon melalui pemakluman melalui emel. Adalah perlu untuk kami nyatakan disini bahawa sebarang permohonan atau pemakluman bagi sebarang pengecualian kehadiran dalam mana-mana prosiding mahkamah adalah tertakluk kepada budi bicara Mahkamah sama ada untuk menerima atau menolaknya. Dalam hal ini kami berpendapat bahawa keputusan yang dibuat oleh Yang Arif Hakim Bicara setelah mengambil kira kegagalan Pemohon untuk hadir.

[18] Sukacita juga untuk kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah. Dalam prosiding interim hadhanah, Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana kes induk hadhanah.

[19] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, pada hemat kami alasan-alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu kesalahaturan yang nyata

atau apa-apa kekhilafan perintah YA Hakim Bicara yang menyalahi hukum Syarak mahupun undang-undang dalam memutuskan perintah interim tersebut. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai sebab untuk campur tangan selain mengekalkan perintah yang telah dikeluarkan.

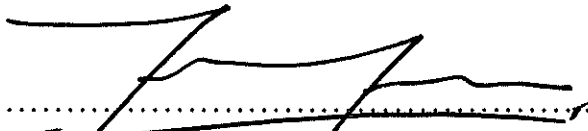
[20] Dengan berpaksikan prinsip keadilan dan demi kebajikan anak-anak, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk sewajarnya disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini sebolehnya dielakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10100-038-0253-2021, MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor